

1509286-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/03/2022

... destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Por fim não há que se desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509286-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1509286-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR CHAVES SIMOES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

VICTOR CHAVES SIMÕES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, segundo apurado, no dia 15 de abril de 2021, por volta das 16h, em ocasião de calamidade pública, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 800, Largo da Batata, Pinheiros, nesta cidade e comarca da capital, vendia e trazia consigo, drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em uma porção contendo a substância Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 16.2g (dezesesseis gramas e dois decigramas), além de uma porção da mesma substância na forma de haxixe, com peso líquido de 21.7g (vinte e um gramas e sete decigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica.

A denúncia foi recebida (fls. 159/160), o réu foi citado e notificado (fls. 182), apresentando resposta à acusação (fls. 178/179).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, durante a qual foram ouvidas duas testemunhas policiais, três testemunhas de defesa e, ao final, foi realizado o interrogatório do réu. (fls. 226/227).

Em suas alegações, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude da prova,

alegando, em suma, que houve invasão da residência sem prévia autorização judicial, no mérito propriamente dito buscou a improcedência da ação penal, e consequente absolvição do réu com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação da conduta descrita na denúncia para a prevista no art 28 da Lei 11.343/06. Em não sendo esse o entendimento, em eventual condenação do acusado pela prática do crime de tráfico, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art 33, §4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, a fixação do regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos, a detração da pena, bem como a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia restaram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão das drogas, (fls. 04/05) e dos objetos (fls. 142/144), laudo de exame químico toxicológico (fls. 126/128), positivo para maconha, relatório final da autoridade policial, bem como pela robusta prova produzida na fase investigativa e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Quanto a autoria, também não há que se falar em dúvida quanto a versão apresentada pelos policiais. Isso porque, os dois policiais ouvidos em audiência de instrução apresentaram versão idêntica sobre a dinâmica dos fatos.

De fato, a testemunha policial Geraldo Gorete dos Santos, ao ser ouvida em juízo, relatou que se dirigiu ao Largo da Batata, juntamente com seu parceiro, após receberem várias denúncias de tráfico de entorpecentes naquele local e ao se aproximarem, após breve campana, observaram o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Ao se aproximarem, as pessoas envolta do acusado e o próprio saíram correndo, após breve perseguição conseguiram apreender o acusado.

Em revista pessoal, localizaram dentro de uma mochila que estava nas costas do réu, algumas porções de substância que aparentavam ser maconha e outras porções de substância que não souberam identificar a natureza, posteriormente identificada como haxixe. Questionado pelos policiais, o acusado confessou informalmente que estava comercializando os entorpecentes para custear seu consumo pessoal. Informou, ainda, que dentro da mochila do réu havia também uma balança de precisão.

Não conhecia o réu de abordagens anteriores. Por fim, esclareceu que o acusado tentou fugir da abordagem policial e foi abordado próximo a uma igreja que há no local, ainda com a mochila nas costas.

No mesmo sentido, a testemunha policial Elói Martins Neto, ouvida em juízo, informou que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde diariamente há ocorrências policiais. Na data em questão, a equipe policial permaneceu em campana e, no local, visualizaram o acusado em atitude suspeita, indicativa de comercialização de drogas. Diante disso, aproximaram-se, ocasião em que o acusado saiu correndo, e após breve perseguição acabou sendo detido.

Em revista pessoal, localizaram com o acusado uma mochila dentro da qual havia diversos objetos, uma balança pequena de prisão, e algumas porções de substâncias que aparentavam ser maconha e haxixe.

Não se recordou se havia dinheiro com o acusado. Relatou, ainda que ao ser indagado sobre as substâncias entorpecentes que estavam em sua mochila, o réu confessou informalmente que vendia drogas para custear seu próprio consumo. Informou que não conhecia o acusado de abordagens anteriores e que a prisão se deu bem próximo ao Largo da Batata, no bairro de Pinheiros.

A testemunha de defesa Jaine Damasceno Araújo, ouvida em juízo, declarou que tem amigos em comum com o acusado. Na data dos fatos, estava em sua casa, que fica localizada no bairro de Santa Cecília, longe do Largo da Batata e que o acusado ali estava e saiu para ir ao mercado comprar algo para o café da manhã e que algum tempo depois foi atender a campainha de seu apartamento e se deparou com o réu algemado na companhia de três homens armados, que informaram que queriam ver a

mochila do acusado. Entregou a mochila de Victor aos homens que a abriram e nada encontram.

Disse, então que um dos policiais começaram a revistar seu quarto e que em nenhum momento houve sua autorização para ingresso na residência. Como não encontraram nada no quarto da testemunha, começaram a revistar os demais cômodos da casa. Disse que se opôs à revista, mas não foi ouvida pelos policiais. Informou que os policiais apreenderam o notebook da testemunha, além de uma balança de precisão, que era usada pela testemunha para controle de dieta e estava guardada na cozinha. Questionada pela acusação, a testemunha Jaine declarou que não morava com o acusado, mas com outros dois amigos; e não soube explicar a razão dos policiais terem se dirigido a sua residência na data dos fatos. Disse que não é usuária de drogas e não sabe informar se o acusado é usuário. Informou que não se lembra do dia exato do ocorrido, mas foi de dia de semana, aproximadamente às 13h50. Não sabe o local exato onde o acusado foi preso, tampouco se com ele fora encontrado entorpecentes, pois estava em sua residência e não presenciou a prisão. Disse, ainda, que não compareceu à delegacia onde o acusado foi encaminhado, pois ficou responsável por contratar um advogado. Não sabe dizer o porquê do advogado que contratou não ter prestado queixa na corregedoria da polícia. Não se recorda do nome dos policiais que teriam invadido sua residência. Disse, por fim, que um dos três policiais estava muito alterado e chegou a apontar a arma em sua direção. Por sua vez, a testemunha de defesa Cristina Marsura, ouvida em juízo, declarou que não conhece o acusado, apenas o viu uma vez no prédio onde mora. Disse que na data dos fatos, estava saindo de seu imóvel em direção ao mercado, quando se deparou com o acusado saindo algemado do prédio.

Nada disse sobre o momento da prisão do réu.

No mesmo sentido, a testemunha de defesa Maria Isabel Cândida Oliveira, ouvida em juízo, declarou que mora e trabalha no prédio onde o acusado foi abordado pelos policiais. Disse que na data dos fatos estava na portaria quando viu o acusado chegando no prédio, seguido pelos policiais. Disse que ficou muito assustada com a abordagem e ficou sem reação. Informou que não viu nada de ilícito encontrado sob posse do acusado. Disse, ainda, que tinha visto o acusado no prédio anteriormente, mas ele não era morador do local. Ademais, relatou ter visto que os policiais subiram com o acusado, mas não sabe para qual apartamento se dirigiram.

Interrogado em juízo, o réu Victor Chaves Simões negou os fatos narrados na inicial. Declarou que na data dos fatos tinha saído da casa da testemunha Jaine para comprar comida e, quando estava retornando ao prédio, foi abordado pelo policiais. Disse que os policiais se aproximaram e de pronto já deram voz de prisão, momento em que foi revista e com ele nada de ilícito fora encontrado.

Ao ser indagado se morava no prédio disse que não e que ali moravam alguns amigos seus e diante disso os policiais decidiram ir ao referido apartamento para fazer revista no local. No interior do apartamento, os policiais revistaram a mochila do acusado, que havia ficado no local, mas não acharam nada de ilícito. Informou que os policiais localizaram a balança de precisão na cozinha da testemunha Jaine, um notebook também de Jaine e conduziram ele e os objetos apreendidos à delegacia de polícia. Informou que negou os fatos na delegacia e desconhece as drogas que foram apreendidas. Informou que não conhecia os policiais antes dos fatos. Disse, ainda, que passou por três delegacias antes de ter sido levado à delegacia onde foi registrada a ocorrência. Informou que não procurou a corregedoria da polícia para relatar o ocorrido, apenas comunicou a sua advogada na delegacia. Contudo, não teve mais acesso à advogada. Nega que tenha sido encontrado qualquer entorpecente sob sua posse, seja pra venda ou pra consumo próprio. Disse que na época dos fatos estava cursando sistemas para a internet na Uninove e trabalhando na área. No dia em questão esta de folga. Por fim, declarou não saber de qualquer rixa dos moradores do apartamento da testemunha Jaine com policiais.

Estas são as provas colhidas nos autos e diante delas, não obstante as alegações da combativa Defesa, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes é medida que se impõe.

Por primeiro, não há que se falar em invasão de domicílio, capaz de macular a prisão em flagrante do acusado, isso porque, conforme se depreende dos depoimentos

colhidos nos autos, em especial das testemunhas de Defesa, apresentados somente em audiência de instrução, ocorrida há aproximadamente 10 meses dos fatos, o réu chegou ao prédio já preso e portanto, a invasão do domicílio da testemunha Jaine, se ocorreu não se deu para a prisão do réu.

Veja-se que, apesar de a testemunha Jaine afirmar que a polícia invadiu sua residência disse eles chegaram ao local na companhia de Victor e não soube informar o local em que a prisão ocorreu, nem mesmo se com o réu fora encontrada alguma substância entorpecente.

No mesmo sentido foram as declarações das outras duas testemunhas ouvidas em juízo que alegaram não saber em que apartamento a polícia entrou com o réu.

Assim, ainda que tenha havido invasão de domicílio, este fato é estranho aos autos, já que se trata de uma aludida invasão que não levou à prisão do acusado.

Veja-se, ademais, que ao contrário do alegado pelo nobre Defensor, tais fatos somente foram alegados após a oitiva e dispensa dos dois policiais e sequer a Defesa requereu que os policiais permanecessem em sala para serem eventualmente reconhecidos pelas testemunhas.

Ademais, durante a oitiva dos dois policiais a Defesa, sequer fez alguma pergunta a eles sobre a alegada invasão de domicílio, e restringiu-se apenas em perguntar onde o réu fora preso, fato este, que segundo os policiais se deu nas proximidades do Largo da Batata.

Outro fato curioso a este juízo, é que o réu ao ser ouvido em sede policial preferiu o silêncio. Já em juízo alegou que sua mãe contratou uma advogada mulher que o acompanhou na Delegacia de Polícia e apesar de ter conhecimento de como a prisão se deu, ou seja, segundo ele, quando chegava ao apartamento de sua amiga e mediante invasão de domicílio, nada fez.

O réu sequer soube indicar o nome da advogada que segundo ele fora contratada por sua mãe.

Também a testemunha que alegou ter sua residência invadida de forma arbitrária pelos policiais, nada fez de concreto, ao contrário, aguardou quase um ano para somente então relatar tais fatos em sede de audiência de instrução.

Se bastasse isso, o mesmo advogado que representou o réu em audiência poucos dias após a prisão, ingressou com pedido de liberdade provisória em favor do acusado e mais uma vez, nada mencionou a respeito de eventual ilegalidade da prisão apenas afirmando que não estavam presentes os requisitos autorizadores da cautelar.

Ora, diante disso, se de um lado temos as versões dos policiais que em todas as oportunidades em que foram ouvidos apresentaram praticamente a mesma versão sobre o prisão do réu, do outro temos a versão três testemunhas de Defesa, que sequer reconheceram os policiais em audiência, já que estes foram dispensados pela própria Defesa, antes mesmo de se iniciar o depoimento de suas testemunhas de Defesa.

Assim é que a versão apresentada pelo acusado e por suas testemunhas de Defesa não fora devidamente comprovada já que as testemunhas Maria e Geralda sequer souberam informar o apartamento para onde o réu e os outros indivíduos se dirigiram.

Ademais, sequer há nos autos provas de que os indivíduos que supostamente teria ingressado no prédio com o acusado seriam os mesmos ouvidos em audiência.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais convergem em mesmo sentido e os dois foram uníssomos em afirmar, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, que a prisão em flagrante ocorreu no Largo da Batata, após campana policial e breve perseguição ao réu.

Ora, o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede

quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição pelos policiais contra o acusado.

Nesse sentido:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos sem geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Dessa forma, considerando-se que o réu não produziu prova alguma capaz de infirmar os fatos que lhe são atribuídos na denúncia, merece total acolhimento a pretensão punitiva.

Isso porque, a forma de acondicionamento das droga apreendidas, bem como a apreensão de balança de precisão e o relato dos policiais que identificaram o acusado em atitude suspeita, típica de comercialização de entorpecentes, são suficientes para caracterizar o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado: "PROVA CRIMINAL - Tóxico - Tráfico - Quantidade da droga apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induzem à certeza de destinação ao comércio - Recurso não provido". (Relator: Lustosa Goulart - Apelação Criminal n.º 159.552-3 - São Paulo - 05.05.94).

Por fim não há que se desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime previsto no art. 28 da Lei de tóxicos já que o próprio réu negou que estivesse na posse de qualquer tipo de entorpecente, não havendo provas no sentido de que os entorpecentes com ele apreendidos eram apenas para sua uso próprio, até, porque, se tratavam de entorpecentes diversos e que foram apreendidos juntamente com uma balança de precisão.

Caracterizada, portanto, a infração penal de tráfico de drogas, passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais, de acordo com a certidão de fls. 35. Assim, favorecem-lhe as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo a sua pena base ser mantida no mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase, há que se considerar que o crime foi cometido durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, em época em que as restrições governamentais ainda estavam vigentes e de maneira mais severa. Desse modo, a pena deve ser agravada em 1/6, alcançando o patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Neste ponto, respeitadas posições em contrário, para esta Magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal.

Neste sentido, já se manifestaram nossos Tribunais:

"Na segunda fase, o crime foi praticado durante o período de calamidade pública causada pela pandemia do COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879/20. Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos" (TJ-SP - PR: 15078616020208260228 SP 1507861- 60.2020.8.26.0228, Relator: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 21/07/2020, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2020).

E ainda: "(...) Por outro lado, cabível a manutenção da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do CP. Ora, o acusado praticou o presente crime durante

período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento, mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença. De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (Apelação Criminal 1509419- 67.2020.8.26.0228. Rel. Edison Brandão. Quarta Câmara de Direito Criminal TJSP. J. 26/01/2021).

"Não há que se falar em afastamento da agravante relativa ao cometimento do crime durante estado de calamidade pública. Isso porque trata-se de circunstância de caráter objetivo, bastando que o crime ocorra durante aquele estado emergencial, não havendo exigência legal da presença de outros requisitos para a sua configuração. Com efeito, é de notório conhecimento o reconhecimento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 até 31 de dezembro de 2020, conforme Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020. Assim, qualquer indivíduo que cometa crimes no período compreendido no citado decreto, como no caso em comento, terá sua pena agravada, haja vista que o agente se vale de uma situação dramática pela qual passa o país para delinquir. Irrelevante, ainda, que não seja o criminoso o provocador da situação excepcional; o que prevalece é sua atitude de se valer das facilidades que dela decorrem, in casu, o isolamento social, com diminuição do policiamento, por exemplo. Sobreleva registrar, outrossim, que as calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento de crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, de defesa por parte da sociedade, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias." (TJSP, Apelação Criminal nº 1512914-22.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camilo Léllis, 4ª Câmara Criminal, j. 09/0).

A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo Autos nº 1509419-67.2020 - "O acusado praticou o presente crime durante período de calamidade pública (pandemia), instituído pelo Decreto Legislativo nº 6, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879, do Estado de São Paulo, ambos em vigor na data em que perpetrado o delito em apreço, não podendo prosperar a alegação de suposto desconhecimento mormente porque decretadas diversas restrições a toda população, para fins de contenção da doença", escreveu o magistrado em seu voto. "De se sublinhar, outrossim, que se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência."

"O Decreto Legislativo nº 06/2020, do Congresso Nacional, e o Decreto Estadual nº 64.879/2020, reconheceram a situação de calamidade pública resultante da pandemia concernente ao novo coronavírus. E o reconhecimento de tal circunstância motiva a incidência de referida agravante.

Ora, diante de tal situação de calamidade pública, a população foi orientada e, em algumas cidades, forçada, a fechar-se em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a cerrar portas. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate à pandemia.

Desse modo, toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida como calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda.

Pese tenha inteligência no sentido de emprestar uma interpretação mais restritiva para a norma prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, a Câmara assentou entendimento pela incidência da circunstância agravante numa situação como a dos autos.

A compreensão é de, com o estado de calamidade provocado pela ação do coronavírus (declarado pelo Decreto Legislativo 06/2020, do Congresso Nacional), "a população

foi orientada e, em algumas cidades, forçada a ficar em casa. Vários estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar. Esforços financeiros e humanos foram dirigidos pelo Estado ao combate da pandemia. Desse modo toda a sociedade foi atingida e sofreu as consequências de referida pandemia, a qual foi reconhecida com calamidade. É indiscutível que o cometimento de qualquer crime durante tal circunstância encontra maior facilidade e superior reprovabilidade, fazendo jus à respectiva exacerbação da reprimenda" (Apelação nº 1512223-08.2020.8.26.0228, rel. Des. Hermann Herschander).

"Não se exige na linha do que penso - que o agente se aproveite especificamente do quadro de pandemia para a realização do crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa. É suficiente, para a incidência da circunstância agravante, que o crime tenha sido cometido durante o período de calamidade pública critério temporal puramente objetivo. Orientação que acompanho nesta oportunidade, em atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC nº 142.585, rel. Min. Celso de Mello).

STJ - "(...) impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61, II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda população do Município, colocando em risco a saúde pública" (HC nº 584.871, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.06.2020, DJe 08.06.2020) TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL (...) Afastamento da agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP Descabimento Crime cometido durante o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 Inexigência legal de outros requisitos para caracterização da agravante (...) Recurso desprovido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1510315-13.2020.8.26.0228, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, J. 16.10.2020). Com idêntico raciocínio: Apelação nº 1507788-88.2020.8.26.0228, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, j. 21.09.2020; Apelação nº 1513982-07.2020.8.26.0228, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Freitas Filho, j. 19.01.2021.

Fátima Gomes, 9ª Câmara Criminal: " Com efeito, na alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal, encontra-se previsão para a agravação da pena diante de circunstâncias que representem o aproveitamento por quem realiza o crime da existência de uma situação de perigo comum. Cabe notar não ser necessário que o sujeito crie a situação de perigo, mas que apenas a aproveite. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. A calamidade produz situação de incapacidade, total ou parcial, e a exigência de abstenção da conduta é maior do que no caso de não concorrerem tais circunstâncias. Na situação especial, o apelante aproveitou-se de acontecimentos de especial relevo para a vida da população. O acontecimento e seus efeitos maléficos devem, obrigatoriamente, ser conhecidos por quem deles conscientemente aproveita-se.

Nesse sentido: "Essa circunstância implica maior gravidade do injusto, de modo a agravar o desvalor da ação, dado que a produção do resultado delituoso se revela mais provável. É necessário que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, da ocasião ou do momento particularmente difícil em que se encontra a vítima, com o fim de dificultar sua defesa. Tal agravante também se fundamenta em razões político-criminais, pois o agente pode prevalecer-se das circunstâncias não apenas para debilitar a defesa da vítima, mas também para facilitar sua impunidade." (PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal: Jurisprudência, Conexões Lógicas com os Vários Ramos do Direito. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 335).

Assim, referida agravante tem natureza objetiva, estampada no artigo 61, inciso II,

alínea "j", do Código Penal e, diante da notória calamidade pública gerada pela pandemia do vírus covid-19, mostra-se absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de afastá-la".

Na terceira fase de aplicação da pena, considerando, a primariedade do acusado, a quantidade de drogas com ele apreendida, e ainda que não há prova de que pertença à organização criminosa, tampouco de que se dedique a atividades criminosas e o caso de se aplicar o disposto no §3º, do art 33 da lei 11.343/06, devendo a pena ser reduzida no máximo legal de 2/3, chegando-se ao total de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa, no mínimo legal, já que não há nos autos provas de sua capacidade econômica.

Em face das decisões reiteradas das cortes superiores, nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que fica ora estabelecida por uma pena de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo da pena substituída e que deverá ser determinada no Juízo da Execução.

Nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal, deixo de aplicar o réu o "sursis".

Por fim considerando que se trata de acusado primário, condenado a crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e ainda considerando o disposto no artigo 33, §2º do Código Penal, fixa-se o regime inicial aberto, em caso de descumprimento.

Tendo em vista que o réu foi solto durante o tramite do processo e que não estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão cautelar, poderá apelar desta em liberdade.

Transitado em julgado, expeça-se guia de execução definitiva.

Comunique-se o IIRGD e o TRE.

Oficie-se também para a destruição integral da droga apreendida, inclusive eventual amostra para contraprova.

Custas na forma da lei. Deixo de isentar o réu do pagamento da referida taxa, já que não compete a este juízo esta decisão, ainda mais porque, não há os autos qualquer prova da condição econômica do réu, consoante entendimento consolidado como se demonstra na Apelação Criminal nº 1504000-37.2018.8.26.0228, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo)

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA